

favorable a la protección de la naturaleza. Esta Corte Constitucional determina, además, que estos principios deben aplicarse también en la interpretación de las propias disposiciones constitucionales, pues ello es lo que más se ajusta a la Constitución en su integralidad y al sentido más favorable a la plena vigencia de los derechos, conforme al artículo 427 de la Constitución.

41. En este marco, los jueces y juezas que conocen acciones de protección y peticiones de medidas cautelares por posibles violaciones a los derechos de la naturaleza están obligados a realizar un examen cuidadoso sobre tales alegaciones y peticiones, en los mismos términos que lo ha establecido esta Corte para los demás derechos constitucionales. En particular, estas peticiones y demandas no pueden ser negadas, como sucedió en este caso en la sentencia de primera instancia, bajo la mera afirmación de que se trata de asuntos puramente administrativos cuyo juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria.¹⁷

Valoración intrínseca de la naturaleza

42. La idea central de los derechos de la naturaleza es la de que esta tiene valor por sí misma y que ello debe expresarse en el reconocimiento de sus propios derechos, independientemente de la utilidad que la naturaleza pueda tener para el ser humano. El artículo 71 de la Constitución lo expresa en los siguientes términos:

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. (énfasis añadido)

43. Se trata de una perspectiva sistémica que protege procesos naturales por su valor propio. De esta forma, un río, un bosque u otros ecosistemas son vistos como sistemas de vida cuya existencia y procesos biológicos ameritan la mayor protección jurídica posible que puede otorgar una Constitución: el reconocimiento de derechos inherentes a un sujeto. En el caso ecuatoriano, hay un reconocimiento general de derechos de la naturaleza en la Carta Fundamental que, como lo expresó la Corte en la sentencia 22-18-IN/21, que hace referencia a derechos de los manglares, puede concretarse en titulares determinados; el reconocimiento específico no implica que sea necesario el reconocimiento para la protección, sino que ayuda a configurar la protección de forma adecuada al titular concreto de derechos, en el presente caso el Bosque Protector Los Cedros.
44. Al respecto es importante comprender el *principio ecológico de tolerancia*, que sostiene que los sistemas naturales solo pueden funcionar adaptativamente dentro de un ambiente cuyas características básicas no han sido alteradas más allá de lo óptimo para ese sistema. Este principio está estrechamente relacionado con el derecho a la existencia y reproducción de los ciclos, pues a medida que un ambiente es modificado, el comportamiento adaptativo del ecosistema se hace más y más difícil y eventualmente

¹⁷ Al respecto, ver sentencias No. 1-16-PJO-CC de 22 de marzo de 2016, No. 989-11-EP/19 de 10 de septiembre de 2019, No. 16-16-JC/20 de 30 de septiembre de 2020.

imposible. Para cada característica particular del ambiente (cantidad de lluvia, humedad, radiación solar, etc.) hay límites más allá de los cuales los organismos ya no pueden crecer, reproducirse y en último extremo sobrevivir.¹⁸ De tal manera que, cuando se supera el nivel de tolerancia, es imposible el ejercicio del derecho a reproducir los ciclos vitales. Así, un bosque protector puede amortiguar un impacto dentro de determinados límites más allá de los cuales perdería su estructura y no podría continuar ejerciendo este derecho a reproducir sus ciclos vitales, como lo establece el artículo 71 de la Constitución.

45. El bosque nublado, que es el caso del Bosque Protector Los Cedros, es uno de los varios tipos de ecosistemas del Ecuador. El Código Orgánico del Ambiente (en adelante “COAm”) en su respectivo glosario define a un ecosistema como “*una unidad estructural, funcional y de organización, consistente en organismos y las variables ambientales bióticas y abióticas de un área determinada*”. En otras palabras, un **ecosistema** es una comunidad o grupo de organismos que viven e interactúan en un ambiente dado.¹⁹ Esto supone que el ecosistema se define tanto por las interrelaciones que involucra como por sus componentes biótico y abiótico (luz solar, agua, minerales y otros).
46. El componente biótico del ecosistema son las especies que lo constituyen. La especie se define como el conjunto de organismos capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil pero no con miembros pertenecientes a otras especies en estado natural²⁰. Muchas veces, a lo largo del tiempo geológico, los individuos que se separan de la población original y se aíslan del resto pueden alcanzar un grado de diferenciación suficiente como para convertirse en una nueva especie.²¹
47. Se considera que un ecosistema diverso es aquel que posee un alto número de especies en interacción. La **biodiversidad** actúa como un *seguro natural* para el ecosistema porque le permite recuperarse ante los eventos que lo afectan. Si hay varias especies que cumplen una función similar, como por ejemplo alimentarse de plantas, es factible que en el caso de que una de ellas disminuya en su número poblacional debido a catástrofes naturales, las otras puedan suplir esa deficiencia y el ecosistema recupere su estabilidad.²² Tanto los ecosistemas con sus especies y biodiversidad son objeto de valoración intrínseca en la Constitución ecuatoriana.
48. La valoración intrínseca de la naturaleza mediante el reconocimiento de derechos es difícil de entender desde una perspectiva rígidamente antropocéntrica, la cual concibe al ser humano como la especie más valiosa, mientras reduce a las demás especies y a la

¹⁸ Goldsmith, E., 1993. *The Way. An ecological World-view*. Shambhala Publications, Inc. Boston.

¹⁹ Fundación Multimedios Ambiente Ecológico. (s.f). *Diccionario Ecológico*. Recuperado de 2021: <http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/diccionarioEcologico/diccionarioEcologico.php3>.

²⁰ UN Glossary of Environmental Statistics. Department for Economic and Social Information and Policy Analysis. Statistics Division. pág. 69.

²¹ Understanding Evolution. (s.f). *Aislamiento Reproductivo*. Recuperado de: https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_44_sp

²² Vargas Ríos Orlando. 2011. *Restauración Ecológica: Biodiversidad y conservación*. Acta Biológica Colombiana. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Vol 16 núm 2. 221-246.

naturaleza misma, a un conjunto de objetos o recursos para satisfacer las necesidades humanas, especialmente las de orden económico.

49. Esta visión de la naturaleza como simple fuente de recursos que se explotan a voluntad ha sido profundamente cuestionada desde diversas vertientes de las ciencias naturales y humanas. Los derechos de la naturaleza representan este cuestionamiento en el mundo del Derecho.
50. La valoración intrínseca de la naturaleza implica, por tanto, una concepción definida del ser humano sobre sí mismo, sobre la naturaleza y sobre las relaciones entre ambos. Según esta concepción, el ser humano no debe ser el único sujeto de derechos, ni el centro de la protección ambiental. Al contrario, reconociendo especificidades y diferencias, se plantea la complementariedad entre los seres humanos y otras especies y sistemas naturales en tanto integran sistemas de vida comunes.
51. En este sentido, esta Corte Constitucional destaca lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en cuanto a los objetivos de la protección ambiental señalados en la Opinión Consultiva 23-17:

*Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.*²³

52. Se trata de un cambio de paradigma jurídico porque históricamente el Derecho ha sido funcional a la instrumentalización, apropiación y explotación de la naturaleza como un mero recurso natural. Los derechos de la naturaleza plantean que para armonizar su relación con ella, sea el ser humano el que se adapte de forma adecuada a los procesos y sistemas naturales, de allí la importancia de contar con el conocimiento científico y los saberes comunitarios, especialmente indígenas por su relación con la naturaleza, sobre tales procesos y sistemas.
53. Esta adaptación debe generarse también en los procesos productivos. En efecto, la propia Constitución reconoce en su artículo 74, que “*las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir*”.
54. En conclusión, la noción de valoración intrínseca de la naturaleza tiene especial importancia para el análisis constitucional relativo a los derechos de la naturaleza, previstos en la Constitución. Puesto que los accionantes afirman en su demanda que la actividad minera en Los Cedros causaría daños graves e irreversibles a las especies en

²³ Corte IDH, Opinión Consultiva 23-17 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, párr. 62. En este mismo sentido: Corte-IDH, Caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs Argentina. Sentencia del 6 de Febrero del 2020, especialmente párr. 203.

riesgo allí presentes y al ecosistema en su conjunto, e invoca al efecto el principio de precaución, la Corte entra a examinar este principio constitucional.

Precaución y prevención

55. La idea esencial del principio precautorio consiste en que, aún ante la falta de suficiente evidencia científica, es mejor no asumir ciertos riesgos cuando estos pudieran derivar en graves daños que pueden incluso ser irreversibles.
56. En el caso bajo análisis, el GAD invocó expresamente el principio precautorio contenido en el artículo 73 de la Constitución en su demanda, para argumentar la violación de los derechos de la naturaleza. Este artículo dispone:

El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

57. Por otra parte, los accionados y en particular la ENAMI EP consideran inaplicable en la presente causa el *principio de precaución*, pues este ya se habría observado justamente al otorgarse el respectivo registro ambiental. Por otra parte, existiría certeza sobre los impactos ambientales de la actividad minera y por tanto lo aplicable en este caso sería el *principio de prevención*.
58. La Corte observa que ni el juez de primera instancia, ni la Corte Provincial analizaron la aplicación en la causa bajo revisión, sea del principio de precaución o el de prevención, pese a constituir una alegación expresa del GAD relevante en este caso.
59. La Corte considera indispensable dilucidar en esta causa el alcance del principio de precaución porque en su artículo 73, la Constitución lo aplica al riesgo de extinción de especies y destrucción de ecosistemas, considerando ambas situaciones como violatorias de los mencionados derechos de la naturaleza, a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración. Todos estos conceptos son relevantes para el caso de Los Cedros.
60. Según el artículo 396 de la Carta Fundamental el *principio de precaución* determina que “*en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas*”.
61. El artículo 396 incluye referencias genéricas de los componentes básicos del principio de precaución en relación a los derechos de la naturaleza y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De forma más específica, el artículo 73 de la Carta Fundamental aplica este principio a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas y alteración permanente de ciclos naturales.

SENTENCIA No. 1149-19-JP/21

VOTO CONCURRENTE

Juez Constitucional Alí Lozada Prado

1. Formulo este voto concurrente porque, si bien estoy de acuerdo con la decisión contenida en la sentencia, disiento parcialmente con su justificación. Las razones de mi discrepancia, que se expusieron en las deliberaciones del Pleno de la Corte Constitucional, se sintetizan a continuación.
2. En la sentencia, se ratificó lo resuelto por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura en la acción de protección N.º 10332-2018-00640, por la que se dejó sin efecto la resolución N.º 225741 del Ministerio del Ambiente que otorgó el registro ambiental para la fase de exploración inicial de la concesión minera N.º MAERA 2017-3159921, proyecto minero Río Magdalena, conformado por las concesiones Río Magdalena 01 (Código: 40000339) y Río Magdalena 02 (Código: 40000340).
3. Una de las argumentaciones que justificaron esta decisión fue que, en el caso, debía aplicarse el principio de precaución, en consideración a las posibles afectaciones del derecho al agua y a que en las áreas concesionadas se encuentra un bosque nublado, específicamente, el bosque protector Los Cedros. En esa argumentación, se estableció que el requisito determinante para aplicar el principio de precaución, la incertidumbre científica, se verifica por la inexistencia de estudios que establezcan el impacto que la actividad minera podría ocasionar en el bosque protector Los Cedros.
4. Debo admitir que doctrinariamente hay diversas maneras de concebir el principio de precaución y, en contraste, el principio de prevención. Sin embargo, considero que la manera de distinguir entre esos dos principios que mejor se ajusta al inciso primero del artículo 396 de la Constitución¹ es la siguiente:
 - 4.1. El principio de prevención prescribe que, ante la certidumbre científica de un daño a la naturaleza o a la salud humana, es *prima facie* obligatorio evitarlo. De aquí se sigue que, contrariamente a lo que se asume en la sentencia, el principio de prevención no implica necesariamente la autorización de la actividad nociva, bien podría impedírsela; todo depende del balance que se haga en el caso concreto entre la obligación –*prima facie*– de evitar el daño y las razones – también *prima facie*– favorables a la actividad de que se trate. Y, por su parte, el principio de precaución no implica necesariamente la prohibición de la

¹ El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

actividad; dicho principio, al igual que el de prevención, solamente contiene una obligación *prima facie* de evitar eventuales daños a la naturaleza o a la salud humana, obligación que debe balancearse con las razones que operen a favor de la actividad de que se trate.

- 4.2. Es decir, no hay razón alguna para vincular el principio de precaución con la prohibición de realizar una actividad y el principio de prevención con su autorización; lo contrario sería paradójico: a menor certeza científica, en la que se aplica el principio de precaución, se podría tomar una decisión de mayor impacto, la prohibición de realizar una actividad, decisión que estaría excluida del espectro de las que se pueden adoptar cuando se tiene mayor certeza científica, es decir, cuando es aplicable el principio de prevención. Pero, más importante inclusive: las decisiones que se pueden adoptar en cada caso específico, ya sea en función del principio de precaución o del principio de prevención, deben estar abiertas al mejor equilibrio posible de los intereses, derechos, principios y valores en juego en cada caso, por lo que no cabe asociar la prohibición o la regulación con uno solo de los mencionados principios.
- 4.3. La diferencia entre el principio de prevención y el de precaución, entonces, estriba en la certidumbre científica y en la incertidumbre científica del daño ambiental, respectivamente: la existencia del principio de precaución supone una ampliación del radio de protección dado por el principio de prevención cuando el conocimiento científico no permite aseverar con seguridad que una cierta actividad produciría afectación a la naturaleza o a la salud humana.
5. Un ejemplo de incertidumbre científica es la relativa a las consecuencias nocivas para la salud humana de las ondas electromagnéticas emanadas de antenas de telefonía celular: es posible que el conocimiento científico del futuro nos diga que dichas ondas son inocuas o que su nocividad es ínfima; de ahí que este sea un típico ejemplo en el que podría aplicarse el principio de precaución. En contraste, en el caso del bosque Los Cedros, el conocimiento científico nos dice que la actividad minera causaría, con certeza, daños ambientales; por consiguiente, el principio que debe operar es el de prevención. La falta de estudios de impacto ambiental respecto de dicho bosque limita la capacidad de caracterizar y dimensionar el daño que la industria minera causaría en la zona y, por tanto, la capacidad de realizar un balance exacto entre el principio de prevención y las razones favorables a la minería. Pero la falta de estudios de impacto ambiental no altera –más bien presupone– la certidumbre científica de que la actividad minera afectaría al bosque Los Cedros; de hecho, la propia sentencia contiene amplia información sobre los impactos que la actividad minera ocasiona en los bosques nublados.
6. En definitiva, por las razones expuestas, considero que si bien correspondía ratificar la decisión adoptada por la sentencia de apelación en el juicio N.º 10332-2018-00640, esta debió adoptarse aplicando el principio de prevención en lugar del principio de precaución pues, en la sentencia, se esgrimen razones del mayor peso para concluir (i) que existe certidumbre científica sobre el daño que la actividad minera provocaría en

el bosque Los Cedros, y (ii) que las razones favorables a la actividad minera no alcanzan a justificar el referido daño.

Alí Lozada Prado
JUEZ CONSTITUCIONAL

Razón.- Siento por tal que el voto concurrente del Juez Constitucional Alí Lozada Prado, en la causa 1149-19-JP, fue presentado en Secretaría General, el 24 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico a las 18:05; y, ha sido procesado conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL

SENTENCIA No. 1149-19-JP/21

VOTO SALVADO

Jueza Constitucional Teresa Nuques Martínez

1. Con fundamento en el artículo 92 y 190 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (“LOGJCC”), formulo voto salvado respecto de la sentencia No. 1049-19-JP (“**sentencia de mayoría**”) que fue aprobada por el Pleno del Organismo en sesión del 10 de noviembre de 2021, con profundo respeto a los argumentos esgrimidos por el juez ponente de la causa y por los jueces constitucionales que votaron a favor de la sentencia, con los antecedentes y razones que expongo a continuación.

Cuestión previa

2. Como cuestión previa, es importante mencionar que la sentencia de mayoría es una sentencia de revisión emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución que la autoriza a expedir sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante para el desarrollo de las garantías jurisdiccionales en casos seleccionados por esta Corte. En los antecedentes procesales de la causa, consta que fue seleccionada por esta Corte para dictar una sentencia de revisión¹ y que luego la suscrita jueza formó parte de la Sala de Revisión² que conoció o aprobó el proyecto de sentencia con la finalidad de que sea conocido por el Pleno del Organismo³.
3. En tal virtud, es imperioso aclarar que los jueces que conformamos la Sala de Revisión en el decurso procesal de las causas constitucionales seleccionadas conocemos un proyecto de sentencia, y que, en tal virtud, al ser un proyecto de sentencia, tales actuaciones no condicionan ni enervan la decisión o voto del juez constitucional en el Pleno del Organismo, una vez que se produzca la deliberación de la causa y el juez forme su criterio sobre esta.
4. Por tanto, se deja constancia que en el presente caso, la suscrita jueza conoció un proyecto de sentencia en Sala de Revisión únicamente con la finalidad de que prosiga la causa, pero que se reservó de forma expresa sus observaciones y criterios,

¹ El 18 de mayo de 2020, con fundamento en los literales a) y b) del numeral 4 del art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), la Sala de Selección de la Corte Constitucional resolvió seleccionar la causa No. 1149-19-JP.

² La Sala de Revisión es parte de la estructura interna de la Corte Constitucional del Ecuador, organizada por el Pleno del Organismo y conformada por tres jueces constitucionales designados al azar. (Artículos 188 numeral 4, 191 numeral 3 y 199 de la LOGJCC).

³ Párrafo 6, sentencia de mayoría.

especialmente del decisorio respecto del caso concreto⁴. De tal suerte, que luego de la deliberación colectiva, por disentir de los criterios formulados en la sentencia que fue aprobada por la mayoría de los jueces constitucionales, expide el presente voto salvado.

Antecedentes y puntos de divergencia con la sentencia de mayoría

5. En la sentencia de mayoría, se revisó la sentencia de segunda instancia emitida por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dentro de la acción de protección No. 10332-2018-00640 presentada por el GAD de Santa Ana de Cotacachi en favor del Bosque Protector Los Cedros, en la cual se alegaron como vulnerados los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y la consulta ambiental. La Corte Constitucional confirmó la decisión adoptada que aceptó la acción propuesta por el GAD de Cotacachi, declaró la vulneración a los derechos de la naturaleza, el derecho al agua y ambiente sano de las comunidades aledañas al Bosque Protector Los Cedros, al derecho a ser consultados sobre decisiones o autorizaciones que puedan afectar al ambiente, ratificó la medida de reparación por la que se dejó sin efecto el registro ambiental y permiso de agua otorgados para las concesiones mineras Magdalena 01 y Magdalena 02; y, ordenó medidas de reparación adicionales.
6. Con estos antecedentes, si bien comparto la invocación de la Constitución, instrumentos internacionales y demás valores y principios constitucionales que protegen los derechos de la naturaleza citados a lo largo del análisis constitucional de la sentencia de mayoría, difiero de su aplicación al caso concreto, principalmente en los siguientes temas:

i) Justiciabilidad de los derechos de la naturaleza

7. En la Constitución del año 2008⁵, en efecto se reconocen los derechos de la naturaleza y a la naturaleza como sujeto de derecho. Coincidió también en la invocación de los instrumentos internacionales relacionados y que conforme al artículo 11 numeral 9, el respetar y hacer respetar estos derechos integralmente, junto con los demás derechos constitucionales, es el más alto deber del Estado⁶. Asimismo, coincidió en el rol de los jueces constitucionales de velar por tales derechos en las causas que se sometían a su conocimiento; sin embargo, considero que los jueces tienen el deber de ceñir sus actuaciones al marco constitucional vigente y al objeto de la garantía jurisdiccional que se active en concreto.

⁴ Acta de sesión del 5 de noviembre de 2020 de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional del Ecuador. En esta se deja constancia que la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez aprobó el proyecto de sentencia dentro del caso No. 1149-19-JP, con la finalidad de que continúe con su trámite y sea puesto en conocimiento del Pleno del Organismo, sin perjuicio de las observaciones formuladas, particularmente en el decisorio del proyecto de sentencia presentado.

⁵ Constitución 2008, preámbulo, artículo 10, 73

⁶ El artículo 277 numeral 1 de la Constitución establece: “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”.

8. En la sentencia de mayoría, se declaran vulneraciones a los derechos de la naturaleza en el marco de una acción de protección, cuyo objeto es precisamente el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial⁷, es decir, se presupone que existe una violación a un derecho constitucional por acciones u omisiones del Estado; sin embargo, a lo largo de la sentencia de mayoría no solo se invoca el principio precautorio relacionándolo al deber del Estado de tomar medidas de prevención frente al daño ambiental⁸ sino que se realizan afirmaciones sobre la incertidumbre o *riesgo* que presupone la aplicación de este principio⁹, generándose una fuerte tensión con el objeto de la garantía jurisdiccional en que tuvo lugar el presente caso; ya que, a diferencia de las medidas cautelares autónomas que

⁷ Artículo 88 de la Constitución de la República

⁸ Sentencia de mayoría: “54. La idea esencial del principio precautorio consiste en que, aún ante la falta de suficiente evidencia científica, es mejor no asumir ciertos riesgos cuando estos pudieran derivar en graves daños que pueden incluso ser irreversibles. 55. En el caso bajo análisis, el GAD invocó expresamente el principio precautorio contenido en el artículo 73 de la Constitución en su demanda, para argumentar la violación de los derechos de la naturaleza. Este artículo dispone: El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

⁹ Sentencia de mayoría: “61. Con base en estas disposiciones, en la legislación ambiental y en el bloque de constitucionalidad,⁹ esta Corte desarrolla los siguientes elementos del principio de precaución: 1) El riesgo potencial de daño grave e irreversible sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, al medio ambiente sano o la salud. Para aplicar el principio de precaución no es suficiente que simplemente exista un riesgo, pues es necesario que este riesgo se refiera a un daño grave e irreversible. El artículo 73 ilustra bien esta situación al referirse a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas y alteración permanente de ciclos naturales, pues todos ellos son daños tan graves e irreversibles que la Constitución los ha incluido en la sección de derechos de la naturaleza, considerándolos una violación de los mismos; 2) Incertidumbre científica sobre estas consecuencias negativas, sea por ser aún objeto de debate científico, por desconocimiento, o por la dificultad de determinar tales consecuencias en virtud de la alta complejidad o numerosas variables involucradas. Esta es la característica fundamental del principio de precaución, y la que lo diferencia del principio de prevención. La incertidumbre científica para efectos del principio precautorio consiste en: la falta de certeza científica, la cual se refiere a efectos relativamente claros o posibles de una actividad o producto, pero sin evidencia adecuada para asignar probabilidades⁹, o en la ignorancia, la cual se refiere al desconocimiento tanto de estas probabilidades como de algunos de los posibles daños o efectos. (...). 3) Adopción de medidas protectoras oportunas y eficaces por parte del Estado. Al existir el riesgo de un daño grave e irreversible y justamente por la incertidumbre del conocimiento científico al respecto, es necesario no asumir el riesgo y que el Estado en el tiempo adecuado y de forma efectiva tome ciertas medidas que eviten⁹ estos posibles efectos negativos. Es decir, que cuando no existe certeza científica sobre el impacto o daño que supone alguna acción u omisión para la naturaleza, el ambiente o la salud humana, el Estado debe adoptar estas medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar tal afectación⁹. Por tanto, el principio de precaución privilegia, frente a la incertidumbre científica, la hipótesis plausible de que suceda el peor escenario: un daño grave e irreversible, aunque este ocurra a largo plazo. Hay que aclarar que la prohibición de un producto o proceso no es la única medida protectora a adoptar, aunque tal prohibición puede justificarse si el potencial daño es muy grave e irreversible.”

pueden ser activadas ante una amenaza¹⁰, la acción de protección procede como garantía de conocimiento, cuando, en efecto, se vulneran derechos constitucionales¹¹.

9. Es de destacar además que la sentencia de mayoría reconoce la existencia del principio de prevención, lo conceptúa y lo diferencia del principio de precaución de la siguiente manera:

*“El principio de precaución se diferencia del principio de prevención en que este último se aplica cuando existe certeza científica sobre el impacto o daño, es decir cuando se conocen con anticipación tanto los efectos como sus probabilidades. En términos del artículo 396 de la Constitución -El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño-. Es decir que **el principio de prevención conlleva la obligación estatal de exigir el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir mitigar y cesar la afectación**¹². (énfasis añadido).*

10. Es decir, la sentencia de mayoría acepta que el principio de prevención opera cuando existe una *afectación*; sin embargo, descarta su aplicación al caso concreto y en su *ratio decidendi* analiza los hechos del caso y las actuaciones de los Ministerios o entidades involucradas en la acción de protección concluyendo que se vulneraron los derechos de la naturaleza en base al principio precautorio. De hecho, en la sentencia de mayoría se realiza un análisis detallado de los elementos del principio precautorio¹³, los aplica al caso concreto, y luego, concluye que no debió haberse concedido el registro ambiental o permisos de agua para la exploración minera en el Bosque los

¹⁰ Artículo 87 de la Constitución. Véase también sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 16-16-JC párr. 35-37: “35. Esta Corte Constitucional ha identificado dos situaciones, no necesariamente secuenciales, en las cuales pueden proceder las medidas cautelares: (1) cerca de producirse una violación (amenaza); (...). El primer momento se da antes de la violación (...) La violación a los derechos no se ha consumado en el primer momento y solo cabría interponer medidas cautelares. Si se está produciendo la violación de derechos, se causa un daño, entonces procede la garantía jurisdiccional de conocimiento que corresponda- por ejemplo, la acción de protección - de forma conjunta con la medida cautelar (...) 36. De esta manera, la Corte realiza una distinción sobre cuándo procede la medida cautelar autónoma (...). Siguiendo este razonamiento, si el objeto es prevenir o evitar la vulneración de un derecho constitucional, se estaría ante una amenaza y, por tanto, procede una medida cautelar autónoma. Mientras que, cuando el objeto es interrumpir o cesar una vulneración de derechos constitucionales que ya se está produciendo, la medida cautelar puede interponerse conjuntamente con una garantía de conocimiento.”

¹¹ Ibídem.

¹² Sentencia de mayoría, párrafo 62.

¹³ Los elementos del principio de precaución implican la identificación de al menos los siguientes elementos: i) El riesgo potencial de un daño grave o irreversible que un producto o el desarrollo de una actividad pueda tener sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, al ambiente sano y la salud. ii) Incertidumbre científica sobre estas consecuencias negativas, sea por ser aún objeto de debate científico, por desconocimiento, o por la dificultad de determinar tales consecuencias en virtud de la alta complejidad o numerosas variables involucradas iii) La adopción de medidas protectoras eficaces y oportunas por parte del Estado. Frente al riesgo de daños graves e irreversibles sobre los cuales no tenemos certeza científica se deben adoptar las medidas que mejor protejan los derechos de la naturaleza, al agua, al ambiente sano y la salud.

Cedros¹⁴. Es decir, la sentencia de mayoría no asume que el principio de precaución esencialmente descansa en la noción de *riesgo* y no de *afectación*, generando tensiones con el objeto del proceso de origen (acción de protección) cuyo objeto precisamente es la *afectación* de derechos constitucionales, y aceptando que es posible conceder una acción de protección ante un *riesgo*; con lo cual disiento expresamente ya que ello es incompatible con el diseño constitucional vigente.

11. En este sentido, si bien no es posible limitar un principio constitucional a una garantía en concreto, es plausible reconocer estrechas relaciones entre principios y garantías. De tal suerte que es evidente que las medidas cautelares autónomas pueden contribuir transitoriamente a la eficacia y oportunidad de las medidas adoptadas en el marco del principio precautorio y no una acción de protección; y que, por otra parte, el principio de prevención se encuentra estrechamente relacionado con el análisis constitucional en una acción de protección en el que puede juzgarse de forma definitiva y declarar la vulneración a derechos de la naturaleza.

ii) La aplicación de las normas y principios constitucionales

12. Para la resolución de casos concretos, es necesario interpretar la Constitución y el ordenamiento jurídico de forma integral. En el presente caso, se trata de concesiones mineras concedidas y la existencia de un Bosque Protector; en tal medida era necesario acudir a las normas y principios constitucionales relativos al derecho a la naturaleza, pero también a las normas y principios constitucionales relacionados a la minería en el Ecuador; en especial el artículo 407 de la Constitución que señala:

“Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. Se

¹⁴ Sentencia de mayoría, **párrafo 160**: “(...) “verificado el riesgo de daños graves o irreversibles a la naturaleza en el ecosistema Los Cedros y a sus especies endémicas bajo alto riesgo de extinción, la Corte considera pertinente la aplicación del principio de precaución y consecuentemente la adopción de medidas protectoras eficaces y oportunas. En ese sentido, tal medida debió traducirse en abstenerse de otorgar el registro ambiental para exploración minera inicial en Los Cedros, el cual se encuentra relacionado a otros actos de autoridad pública anteriores y posteriores, así como a actuaciones de ENAMI EP y Cornerstone en la fase de exploración inicial “ (...); **párrafo 135**: “Así, esta Corte con base en la información revisada y que ha sido sintetizada en párrafos anteriores ha observado que existen motivos razonables que evidencian que la realización de la actividad minera podría provocar una afectación grave en el ejercicio del derecho al agua de las poblaciones aledañas al Bosque Protector Los Cedros, así como también, al ecosistema. En este escenario, el principio precautorio no fue observado por el MAAE, ni por Senagua. Consecuentemente, este Organismo concluye en la vulneración de este principio aplicado al derecho al agua y considera que no debe realizarse actividad minera en el Bosque Protector Los Cedros”; **párrafo 252**: “En el caso bajo análisis, la Corte observó que el MAAE no cuenta con dicha información sobre el bosque Los Cedros y, como se ha visto en las secciones anteriores de esta sentencia, tampoco ha desarrollado una política pública para un manejo acorde a las características de este ecosistema. Esta grave falencia derivó en la emisión del registro ambiental sin las precauciones necesarias afectando el derecho al ambiente sano”.

prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.

13. La sentencia de mayoría, luego de referir el artículo 407 de la Constitución en el análisis del caso concreto afirma:

*“140. Esta interdependencia eco-sistémica es una de las razones por las que la Corte **no puede aceptar la interpretación de los accionados en el sentido de que el artículo 407 de la Constitución que prohíbe actividades extractivas de recursos no renovables en las áreas protegidas, centros urbanos, y en zonas declaradas como intangibles tiene un carácter excluyente y taxativo.** Si bien es claro que en esta disposición el constituyente prohíbe actividades extractivas expresamente en estas áreas, **de ello no se concluye que tales actividades están automática o incondicionalmente autorizadas en el resto del territorio nacional, o que, verificadas las condiciones constitucionales y legales, no se puedan restringir o suspender tales actividades en zonas distintas, bajo un análisis caso a caso.***

*141. En efecto, **no sería lógico afirmar que los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, y el derecho humano al ambiente sano y equilibrado tienen vigencia sólo en las áreas protegidas y zonas intangibles. Por el contrario, las obligaciones de protección de estos derechos rigen para las autoridades públicas en todo el territorio nacional, y deben ser por tanto analizadas conforme a la Constitución y la normativa infraconstitucional al autorizar, restringir o regular dichas actividades extractivas”.** (énfasis añadidos)*

14. La suscrita jueza, según su criterio, disiente estas afirmaciones por dos razones: 1) Estas afirmaciones presuponen que la actividad minera afecta por sí misma la naturaleza, el derecho al agua o al ambiente sano y equilibrado; 2) Extienden el ámbito de la prohibición constitucional establecida en el artículo 407 de la Constitución.
15. En relación a lo primero, considero que la actividad extractiva por sí sola no genera destrucción de la naturaleza (especies, ecosistemas) ni vulnera derechos de la naturaleza. En primer lugar, las actividades de extracción para que existan como tal deben cumplir varias fases y estudios que se encuentran plenamente regulados para que se ejecuten actividades mineras con responsabilidad ambiental. De ahí que, este Organismo ha reconocido que, en atención al artículo 27 de la Ley de Minería, la expresión “explotación minera” debe entenderse como la ejecución de actividades que han observado el orden secuencial siguiente “(i) prospección, (ii) exploración, (iii) explotación, (iv) beneficio, (v) fundición, (vi) refinación, (vii) comercialización y (viii) cierre de minas”¹⁵ y solo con la consecución de dichas actividades de forma secuencial, se podrían alcanzar los objetivos que se persiguen al desarrollar actividades mineras con responsabilidad ambiental. Aquello debe de entenderse en observancia a las excepciones reconocidas en el texto constitucional, respecto a la prohibición de todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas¹⁶.

¹⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 1-20-CP/20. Párr. 36

¹⁶ CRE: “Art. 407.- *Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de*

16. En el mismo sentido, la Corte ha concluido que *“no es posible realizar la explotación sin que previamente se hayan desarrollado actividades de prospección y exploración; y a su vez, no es posible llegar a la fase de comercialización si es que previamente no se ha realizado la fase de explotación; pese a que dichas actividades no necesariamente recaen en un mismo sujeto de la actividad minera (...)”*¹⁷.
17. Esta Corte también ha hecho énfasis en que es necesario realizar estudios ambientales técnicos e independientes que garanticen los derechos de la naturaleza: *“las autoridades destinadas a emitir estos permisos deben ser garantes de los derechos de la naturaleza y del acceso al agua. Por lo tanto, deben ejercer un estricto control del cumplimiento de requisitos constitucionales, legales e infralegales y anticipar la responsabilidad que podría implicar el emitir autorizaciones que supongan vulneraciones de derechos constitucionales por no haber adoptado las previsiones necesarias.”*¹⁸
18. Por tanto, considero que cumpliendo con los requisitos de cada fase existe la posibilidad de que el Estado a través del órgano técnico, autorice la actividad minera con responsabilidad ambiental, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales, sin afectación de los derechos de la naturaleza u otros.
19. En cuanto a lo segundo, la interpretación del artículo 407 de la Constitución que se da en la sentencia de mayoría, no solamente reconoce la existencia de la prohibición a la actividad extractiva en áreas protegidas establecida en el artículo 407 de la Constitución -lo cual es ineludible porque la norma es clara en su texto- sino que amplía su alcance. En el análisis constitucional efectuado, bajo la incertidumbre del daño que se puede ocasionar, se afirma que la prohibición constitucional puede regir en *“zonas distintas”* a las determinadas por la misma norma constitucional. De tal suerte que, a mi juicio, se está condicionando las actividades extractivas por la *“incertidumbre”* de los efectos que podría ocasionar y ocasionando una indeterminación respecto de los territorios en los que se podría realizar actividades extractivas. Esto, considero, va en desmedro de las mismas competencias estatales y exclusivas¹⁹ para delimitar áreas protegidas o zonas intangibles, porque se diluye su diferenciación con el resto del territorio; y, además condiciona el desarrollo de un sector estratégico²⁰ como la explotación regulada de los recursos naturales del Estado que además son de propiedad de este y la consecuente participación del Estado en los

interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles.”

¹⁷ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 6-20-CP/20. Párr. 43

¹⁸ Corte Constitucional, Sentencia No. 32-17-IN/21, párr. 73.

¹⁹ Artículo 261.3 de la Constitución

²⁰ Artículo 313 de la Constitución.

beneficios del aprovechamiento de estos recursos, que se encuentran reconocidos y normalizados constitucionalmente²¹.

20. A criterio de la suscrita jueza, el texto constitucional debe ser interpretado de forma armónica con los derechos constitucionales, pero también con las normas que regulan el sector estratégico de la actividad minera. Por otra parte, si bien coincido en la protección de los derechos de la naturaleza, al agua o al medio ambiente sano, en que estos son justiciables²² y en su desarrollo progresivo a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas²³, no es factible otorgarle a estos derechos un carácter omnímodo, absoluto o prevalente sobre otros derechos o normas constitucionales llegando al punto de excluir toda actividad extractiva; más aún, cuando en la norma constitucional expresamente reconoce limitaciones. En el caso, el mismo artículo 407 de la Constitución reconoce que la prohibición constitucional de las actividades extractivas en áreas protegidas tiene una excepción en aras del interés nacional, pues es factible promocionar un mecanismo de democracia directa como la consulta popular e intervención del Ejecutivo y la Asamblea para realizar actividades extractivas en tales áreas.
21. Tampoco es factible extender el alcance de una norma constitucional en desmedro de su texto y voluntad del constituyente, ya que la Constitución impone el deber de interpretar las normas constitucionales *“por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”*²⁴; por tanto, disiento de las afirmaciones antes señaladas de la sentencia de mayoría y considero que la aplicación del artículo 407 de la Constitución debe realizarse y aplicarse a casos concretos respetando su texto y voluntad del constituyente.

iii) El desarrollo progresivo de los derechos y su aplicación a casos concretos

22. Como se dijo el desarrollo de los derechos es progresivo, sin embargo, en el marco de la seguridad jurídica, deben analizarse los casos según el escenario constitucional y jurisprudencial vigente a la época de los hechos. En la sentencia de mayoría, se realizan importantes desarrollos jurisprudenciales para definir el principio precautorio, y estándares para la aplicación de una consulta ambiental.

²¹ Artículo 408 de la Constitución

²² Artículo 11.3 de la Constitución

²³ Artículo 11. 8 de la Constitución.

²⁴ Artículo 427 de la Constitución.

23. Si bien se citan normas constitucionales y legales que referían al principio precautorio²⁵ y otras relativas a la consulta ambiental²⁶, debe reconocerse que estas normas por sí solas no desarrollan los estándares ni el contenido de estas instituciones a cabalidad y que más bien se las está dotando de contenido de forma importante en la sentencia de mayoría.
24. Coincidió en la vigencia constitucional del principio precautorio para protección de los derechos de la naturaleza, en la realización de la consulta ambiental en los términos previstos en la Constitución y en los estándares que se han desarrollado para proteger el derecho de participación de la ciudadanía; sin embargo, disiento en que dichos estándares que están siendo prácticamente creados en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana en este momento sean aplicados de forma retroactiva a la acción de protección que tuvo lugar en el caso seleccionado en la presente causa.
25. En este sentido, si bien es cierto que, en ejercicio de las competencias de revisión, la Corte Constitucional del Ecuador, tiene las posibilidades de desarrollar jurisprudencia vinculante y de revisar el caso concreto. Esta última actividad de revisar el caso concreto está supeditada, como se dijo, al escenario constitucional y jurisprudencial de los hechos; por tanto, si bien comparto el desarrollo jurisprudencial que se ha dado como jurisprudencia relevante, principalmente, en el principio precautorio y los estándares de la consulta ambiental, no comparto en que sean aplicados al Estado ecuatoriano en el caso concreto y consecuentemente declararlos vulnerados²⁷.
26. En este sentido, considero que no era factible reprochar al Estado por incumplir el principio precautorio sobre la base del contenido que se está creando en la presente sentencia ni tampoco haber declarado que se vulneró la consulta ambiental con los estándares desarrollados. A mi juicio, pudieron haberse analizado los hechos y las cuestiones medulares sobre la base del escenario constitucional y jurisprudencial de la época y, para casos posteriores, establecer los estándares para la protección de la naturaleza a través del principio precautorio y la aplicación de la consulta ambiental; inclusive, de haberse acreditado vulneraciones que no fueron reparadas por las instancias inferiores en las sentencias sujetas a revisión, era factible realizarlo, teniendo en cuenta además que la acción de protección fue previamente concedida y que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura de 19 de junio de 2020 ya había dejado sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados para las concesiones mineras Magdalena 01 y Magdalena 02. Es más, era factible, en respeto de la seguridad jurídica, ampliar las medidas de reparación con

²⁵ Artículo 73 y 396 de la Constitución, artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental vigente a la fecha de emisión del registro ambiental, entre otras.

²⁶ Artículo 398 de la Constitución, artículo 82 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), artículo 184 del Código de Ambiente, Artículo 68 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental (LGA) fue la normativa aplicable para otorgar el registro ambiental, Artículo 87 Ley de Minería, entre otros.

²⁷ Véase el decisorio de la sentencia de mayoría, declara vulnerados los derechos de la naturaleza, el derecho al agua y ambiente sano de las comunidades aledañas al Bosque Protector Los Cedros, al derecho a ser consultados sobre decisiones o autorizaciones que puedan afectar al ambiente.

medidas de no repetición o de reparación integral, pero sobre la base de la aplicación de normas previas, públicas, claras conforme al artículo 82 de la Constitución.

Por todas las consideraciones expuestas, disiento de la decisión arribada en la presente causa.

Dra. Teresa Nuques Martínez
JUEZA CONSTITUCIONAL

Razón.- Siento por tal que el voto salvado de la Jueza Constitucional Teresa Nuques Martínez, en la causa 1149-19-JP, fue presentado en Secretaría General, el 24 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico a las 20:57; y, ha sido procesado conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL

SENTENCIA No. 1149-19-JP/21

VOTO SALVADO

Jueza Constitucional Carmen Corral Ponce

1. Con el acostumbrado respeto a los argumentos esgrimidos por el juez ponente y por los magistrados que votaron a favor de la causa N° 1149-19-JP de 10 de noviembre de 2021, me permito disentir con el voto de mayoría respecto de algunos razonamientos que soportan el análisis de la sentencia de revisión de la garantía jurisdiccional de acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi en favor del “Bosque Protector Los Cedros”¹. La disidencia gira en torno a los siguientes argumentos:

Aspectos generales:

2. En el párrafo 51 de la sentencia de mayoría se menciona que: “[l]os derechos de la naturaleza plantean que para armonizar su relación con ella, sea el ser humano el que se adapte de forma adecuada a los procesos y sistemas naturales”, tal aserción, aunque aparente ser un mero postulado ontológico comporta en sí misma una delimitación conceptual poco equilibrada entre lo que representa la relación “*ser humano-naturaleza*”; puesto que en contraste con el antropocentrismo utilitarista, esta idea se orienta hacia un ecocentrismo extremo en el que se condiciona la actividad humana (sin importar distinciones) hacia la proscripción de cualquier modificación -acaso permanente- de un entorno natural.
3. Por lo tanto, no se trata de establecer la preeminencia de la naturaleza sobre el ser humano, ni viceversa; ya que ello conduce incorrectamente a un concepto binario reduccionista de una u otra postura. Debe existir un equilibrio entre la protección ambiental, que procede conforme los procedimientos y reglas previstas en el ordenamiento jurídico y el desarrollo de las actividades antrópicas de una manera racional, sostenible y sustentable. De tal manera, que así como resulta importante proteger al entorno natural cuando se encuentre en riesgo un ecosistema, también es trascendente promover el desarrollo y la distribución equitativa de la riqueza generada por la gestión responsable de los recursos naturales².
4. Es así que, constitucionalmente se establece que la protección ambiental se despliega en varias figuras que deben ser debidamente entendidas e integradas para su operatividad. El artículo 14 de la Carta Constitucional determina que: “**Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (...)** Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

¹ Dentro del proceso signado con el No. 10332-2018-00640.

² Art. 3.5 de la Constitución de la República.

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la **prevención del daño ambiental** y la recuperación de los espacios naturales degradados” (énfasis agregado). En tanto que el artículo 73 inciso primero de la Constitución establece que: “El Estado aplicará medidas de **precaución** y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la **destrucción de ecosistemas** o la alteración permanente de los ciclos naturales” (énfasis añadido).

5. La ubicación de estas dos disposiciones constitucionales dan cuenta de su alcance y esencia. El artículo 14 consta en el Título II “Derechos”, Capítulo Segundo “Derechos del buen vivir”, Sección Segunda “Ambiente sano”, de la Carta Constitucional, es decir, reconoce un derecho de las personas; mientras que el artículo 73 que se encuentra en el Título II “Derechos”, Capítulo Séptimo “Derechos de la naturaleza”, de la Constitución, contiene un derecho reconocido al entorno natural. De ello se desprende que la “prevención” es una figura aplicable para precautelar el derecho de las personas ante el riesgo de un daño ambiental; en tanto que la “precaución” es una medida para salvaguardar a la naturaleza ante el peligro de la destrucción de los ecosistemas.
6. Es por ello, que en el Título VI “Régimen del buen vivir”, Capítulo Segundo “Biodiversidad y recursos naturales”, Sección Primera “Naturaleza y ambiente” de la Norma Suprema, en el artículo 396 primer inciso determina en la primera parte que: “El Estado adoptará las políticas y **medidas** oportunas que **eviten** los impactos ambientales negativos, **cuando exista certidumbre de daño**” (énfasis agregado) ; y, en la segunda parte establece que: “**En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas**”. (énfasis añadido)
7. De la lectura sistemática de estas disposiciones constitucionales se denota lo siguiente: **i)** que los mecanismos que evitan un eventual daño ambiental -como afectación al derecho de las personas al ambiente sano- corresponden al concepto de la *prevención*, por ello, el ordenamiento jurídico prevé medios para prevenir este riesgo como son los estudios de impacto ambiental *ex ante* y *ex post* en las etapas que sean exigibles y que se basan en la certidumbre del daño; y, **ii)** que las medidas protectoras ante el peligro de la destrucción de ecosistemas, forman parte de los derechos de la naturaleza, que se encuadran dentro de la figura de la *precaución*, habilitando la intervención del Estado en caso de duda o cuando no haya evidencia científica del daño en función del principio *indubio pro natura*.
8. Dentro de este contexto cabe relieves que el principio de *prevención* que regularmente opera durante el decurso de una actividad sujeta a autorización, se materializa a través de mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el procedimiento para la obtención de licencias y autorizaciones administrativas, cuya finalidad es la de prever el posible daño ambiental y actuar en base a ese conocimiento en merced de la protección del medio ambiente; en tanto que el principio de *precaución* se aplica en los casos en que ese conocimiento previo está completamente ausente y el riesgo del daño que puede sobrevenir es en extremo incierto, al punto de que no se pueda tener un conocimiento al menos generalizado de los efectos de una determinada actividad.

9. Estas dos figuras no pueden confundirse, ya que responden a su propia razonabilidad, de tal forma que si una actividad sobre los recursos naturales ha sido autorizada y cuenta con estudios, planes y permisos, la posibilidad para precautelar posibles daños y contingencias ambientales será indudablemente la *prevención*, mas no la *precaución* ambiental. Es decir, no se puede dictar una intervención estatal aduciendo *precaución* del riesgo, si se han conferido autorizaciones, estudios y permisos sobre la base del principio de *prevención*, que actúa debido al conocimiento previo y generalizado de la certidumbre del daño; esto sin perjuicio de que se produzca en efecto un daño ambiental, a pesar de la *prevención*, y se genere la responsabilidad ambiental objetiva e imprescriptible según los incisos segundo a cuarto del antedicho artículo 396 de la Constitución.
10. Por otro lado, no se puede obviar como lo hace la sentencia que en el presente caso se han emitido los respectivos permisos, los cuales se han consignado en aplicación del principio de *prevención*, toda vez, que el ejercicio de las labores mineras no es una actividad en reciente descubrimiento sobre la cual no exista un amplio registro de sus efectos; por lo que se denota que la sentencia no parte -como debería- de la premisa de la existencia de una *prevención* ambiental dada por la información concreta sobre los impactos de los proyectos mineros autorizados, para en su lugar dar paso a una malentendida *precaución* alegándose la falta de información específica, lo cual deviene en improcedente.

Efectos concretos:

11. De todas formas, más allá de estas diferencias generales o abstractas el fallo de mayoría en comento, plantea problemas de practicidad y estos vienen dados por la forma en cómo se concibe al principio de *precaución* ambiental. En el párrafo 61.2 de la sentencia se menciona que la incertidumbre científica se aplica “[a]unque se conozca a priori todos o algunos de los potenciales daños o efectos negativos que estos producen, [pero] no se han establecido de forma científica, estableciendo probabilidades, las específicas relaciones causa-efecto entre la actividad o producto y dichos daños. Esta limitación del conocimiento científico puede deberse a la alta complejidad de un sistema o fenómeno. La incertidumbre científica puede también evidenciarse en debates científicos no resueltos o ausencia o insuficiencia de conocimientos sobre estos efectos”.
12. En relación a lo anterior se coincide en que el cumplimiento del principio de *precaución* debe ser sujeto a un riguroso escrutinio técnico; sin embargo, inquieta el alcance con el cual se está valorando a este principio ambiental, en razón de que el estándar que se estaría imponiendo, no es el de superar un umbral de incertidumbre científica (conocer o tener registros de los posibles efectos de la actividad, obra o proyecto de modo general), sino el de determinar sus consecuencias o impactos dentro de un entorno específico, situación que es propia de un análisis casuístico de factibilidad (estudios de impactos ambientales), lo que obviamente no se circunscribe a un contexto de incertidumbre de la comunidad científica, sino a una insuficiencia de información técnica en concreto.

13. Además, se percibe una especie de sesgo hacia las actividades extractivas entendiéndolas como altamente perniciosas y destructivas, sin considerar la existencia de otros tipos de conocimientos generalizados sobre la minería, tales como sus métodos de extracción y los posibles efectos no lesivos que ellos podrían generar en entornos naturales de alta sensibilidad³.
14. Dicho esto, se debe considerar que dadas las connotaciones y variaciones de la ejecución de una actividad tan técnica (como la minería) se pueden prever o conjeturar sobre sus posibles contingencias y riesgos ambientales, pero no tener una certeza científica invariable de lo que podría o no ocurrir (como parece ser el estándar que se exige); es por ello, que en los planes y estudios ambientales se consideran estos aspectos (riesgos) para la aprobación de los respectivos permisos, así como la ejecución de actividades de monitoreo, seguimiento, inspecciones y auditorías ambientales.
15. En ese sentido, la certeza puede circundar en que existan posibles riesgos y que se afecten especies, pero no por ello se debe prohibir la ejecución de las actividades, obras o proyectos en todos los casos, pues es ahí donde entra en juego el principio de prevención para mitigar o eliminar las consecuencias ambientalmente nocivas de la actividad.
16. Con la forma en cómo se erige la sentencia in examine, da impresión de que basta con que exista un riesgo para que se prohíba una actividad, lo cual puede generar la errada percepción de que nuestro modelo de justicia constitucional contempla una fórmula de restricción absoluta de posibles riesgos ambientales, pudiéndose incluso vaciar de contenido la dispensa contenida en el artículo 407 de la CRE.
17. Lo dicho precedentemente son cuestiones trascendentales que no han pasado desapercibidas en nuestra Carta Suprema, no se debe perder de vista que ha sido el propio constituyente quien en el artículo 407 de la Constitución de la República (“CRE”) contempló la posibilidad de autorizar excepcionalmente “vía declaratoria de interés nacional” el ejercicio de actividades extractivas de recursos naturales no renovables dentro del sistema nacional de áreas protegidas (ecosistemas más frágiles que los bosques protectores); por lo cual, es evidente que el paradigma constitucional ecuatoriano plantea una justa medida entre el marco de protección de los derechos de la naturaleza y el impulso de actividades productivas por parte del Estado, como un medio idóneo para alcanzar una efectiva promoción de derechos (v.gr., educación, salud, vivienda, empleo), así como la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo⁴.

Aplicación del principio de prevención:

18. Para este caso en particular se considera que existen algunos matices que nos hacen inferir

³ Cabe relieves que existen varios métodos de bajo impacto ambiental que se realizan dentro de la fase de exploración o identificación de las características del yacimiento, por ejemplo: la fotogeología, gravimetría, radiometría, etc.).

⁴ Arts. 275 y 276 de la Constitución de la República.

que lo más idóneo sería la aplicación del principio de prevención en lugar del principio de precaución. Así, por ejemplo, en la sentencia existe evidencia y en ese contexto, certeza científica de las especies que habitan en la zona, niveles de vulnerabilidad y datos de su georreferenciación, al igual que la identificación de las fuentes hídricas (párrs. 70 al 110); información valiosa con la que ciertamente se permitirían generar rigurosas medidas de mitigación o disminución de impactos ambientales negativos; es decir, aplicar los elementos de la prevención de los posibles efectos adversos de la actividad.

19. Ahora bien, preocupa de sobremanera que la Corte Constitucional llegue al punto de desbordar sus competencias y establezca conclusiones técnicas de altísima complejidad como que: “1) *la fragilidad, biodiversidad, endemismo, y en general, un nivel de biodiversidad y complejidad que implica un número tan alto de variables y relaciones que imposibilita un estudio adecuado de las probabilidades del impacto ambiental de la minería metálica en el bosque (...) esto hubiera llevado al MAE a considerar que actualmente no existe la certidumbre o certeza científica planteada por los accionados sobre el tipo y magnitud del impacto o daño de la explotación de minería metálica en este bosque*”; es decir, que este Organismo asume y da por sentado que ningún estudio o evaluación de impacto ambiental podría resultar suficientes a fin de demostrar técnicamente la plausibilidad de ejecutar actividades mineras de forma ambientalmente responsable, sustentable y sostenible dentro del bosque “Los Cedros”.
20. Todas estas apreciaciones provocan que se termine por restarle valor y eficacia práctica al principio de prevención orillándolo a un nivel de inaplicación en el que exista una tendencia a prohibir por precaución el ejercicio de actividades (que no cuentan con estudios definitivos), cuando su esencia es justamente la de reducir las posibles contingencias que se han logrado advertir en virtud de la información con la que se cuenta.
21. En la sentencia de mayoría se señala que por el principio procesal de inversión de la carga de la prueba le correspondía al titular de la concesión minera y sus operadores justificar con los **estudios de impacto ambiental** que no existiría una afectación grave o irreversible al ecosistema del bosque protector “Los Cedros”. Este tipo de exigencias en una etapa donde no se requiere contar con dichos estudios especializados, contrarían el ámbito de protección del derecho a la seguridad jurídica de los promotores de la actividad; por lo que, dentro de este caso no se estima prudente que se impongan como estándares probatorios mínimos requerir infaliblemente tal información, más aún cuando el andamiaje normativo ambiental y minero no obligaba a contar con estudios a “mediano y largo plazo” para una fase o actividad que en ese estado del procedimiento no resultaba exigible.
22. Con este tipo de afirmaciones concurren al menos tres posibles escenarios gravosos, a saber: **i)** a pretexto de efectuar un análisis jurisdiccional se estaría hasta cierto punto socavando las competencias técnicas del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; **ii)** se estaría tomando al principio de precaución ambiental como una regla de proscripción radical; y, **iii)** se está invocando erradamente una supuesta incertidumbre

científica del daño para justificar la ausencia de información técnica específica que, dicho sea de paso, conforme la ley de la materia no se requería para la fase de exploración minera inicial.

23. En cuanto a la adopción de las medidas de reparación se observa que las mismas no se compadecen con la naturaleza del principio de precaución. Aquí cabe realizar una disquisición importante, ya que conforme lo determina el artículo 396 de la CRE, el Estado deberá adoptar las medidas protectoras eficaces y oportunas, aun cuando no existe evidencia científica del daño; de la exégesis de esta regla constitucional se colige que la intervención estatal se encuentra condicionada a la inexistencia de “la certeza del daño”; en consecuencia, las medidas que se impongan en virtud de este principio deberían considerar al menos tres aspectos fundamentales:

- Estas tienen una naturaleza *-prima facie-* cautelar, es decir, que pueden estar sujetas a criterios de revisibilidad acorde a la información posterior que se pueda aportar en el proceso.
- Serán graduales en el sentido de que deben considerarse aspectos que no impliquen *ab initio* una restricción absoluta y perenne, por ejemplo, la posibilidad de disponer como primera opción la suspensión de la actividad, obra o proyecto.
- Serán definitivas de *última ratio*; esto es, cuando dentro del conocimiento de la garantía jurisdiccional de tutela de derechos se verifique la existencia de un obstáculo técnico o jurídico que resulte manifiestamente insubsanable, como cuando se requiera de la implementación de una tecnología inexistente o experimental.

24. Si se toma como referencia la *ratio decidendi* del precedente objeto de discusión se colige que el mismo ratifica la sentencia de segunda instancia emitida dentro de la garantía jurisdiccional materia de revisión, pero mediante otro análisis en el que se aplica el principio de precaución para ordenar *-inter alia-* que: “No deben realizarse actividades que amenacen a los derechos de la naturaleza dentro del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros, lo cual, incluye la actividad minera y todo tipo de actividad extractiva (...) La Empresa Nacional Minera EP y las empresas aliadas o asociadas deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros, retirar la infraestructura que haya sido edificada en dicho bosque, si la hubiera, y reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura o por la apertura de senderos”⁵.

25. Es por ello, que el presente caso donde se han otorgado concesiones, realizado inversiones, conferido permisos y consolidado situaciones jurídicas, lo más adecuado no es disponer una prohibición absoluta de las actividades, sino aplicar el principio de prevención para que en un espacio de tiempo prudencial los gestores de la actividad puedan presentar estudios o evaluaciones de impacto ambiental serias que determinen si

⁵ Párrafo 348, literales a) y b).

es factible o no continuar con el desarrollo de otras fases de la actividad minera, sin que se tenga que subvertir el orden normativo contemplado en la legislación vigente. La suscrita juzgadora enfatiza en que debe existir una debida armonía entre los principios de precaución y prevención ambiental, sin que el primero termine por desplazar al segundo, exigiendo como en este caso un rigor científico que puede ser previsible, pero no exacto o invariable.

Consideraciones adicionales:

26. A modo de corolario, **a pesar de que no comparto** con el razonamiento esgrimido en la sentencia de marras, es importante dejar en claro un asunto del cual no se ocupa el voto de mayoría, esto es, que si se ha considerado, bajo su criterio, que proceden medidas de reparación adicionales a las dispuestas en el proceso de origen, se debió establecer de forma clara este aspecto, no bastando con disponer de forma indeterminada que se prohíben las actividades mineras y se retire la infraestructura existente dentro del bosque “Los Cedros”.
27. Como se ha podido evidenciar dentro del caso *in comento*, la gestión de la actividad minera dentro del referido bosque también involucra a personas jurídicas de derecho privado⁶, por lo que el fallo objeto de divergencia debió realizar un pronunciamiento al menos sumario sobre las repercusiones que revisten tales medidas en relación a estas terceras personas, mismas que forman parte del encadenamiento de la actividad minera⁷.
28. De manera que, si el fallo de mayoría consideró que existe una vulneración de derechos humanos y de la naturaleza (cuestión que no comparto), se debió advertir sobre la aplicación de las causales de caducidad de derechos mineros prescritas en los artículos 115 y 117 de la Ley de Minería, con miras a que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; y, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables incoen las acciones administrativas conducentes a revertir y anular los contratos, títulos, licencias, permisos y concesiones mineras catastradas dentro del bosque protector “Los Cedros”. Los aludidos artículos disponen que:

“Art. 115.- Caducidad por Declaración de Daño Ambiental.- (Reformado por la Disposición Reformativa Novena del Código Orgánico del Ambiente, R.O. 983-S, 12- IV- 2017).- El Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan daños ambientales, sin perjuicio de la obligación del concesionario de reparar los daños ambientales causados.

⁶ En el párr. 157 de la sentencia de mayoría se reconoce que: “A raíz de estos actos de autoridades públicas, las empresas ENAMI EP y Cornerstone, pública la primera y privada la segunda, iniciaron en Los Cedros actividades de exploración minera en su fase inicial (...)”.

⁷ Vale aclarar que los derechos mineros no comprenden únicamente el otorgamiento de concesiones mineras, ya que como lo señala el artículo 17 de la Ley de Minería, estos abarcan: “*aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización*”.

La calificación del daño ambiental, se efectuará de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico del Ambiente. Cuando haya afectación de recursos hídricos a causa de las actividades mineras, la calificación de daño ambiental deberá considerar el pronunciamiento de la autoridad única del agua.

El procedimiento y los requisitos para la declaración de daño ambiental estarán contenidos en el reglamento general de la normativa ambiental vigente”.

“Art. 117.- Caducidad por Violación de los Derechos Humanos.- El Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de una concesión minera si se ha producido violación de derechos humanos, ya sea por parte del concesionario o de sus representantes, así como de sus contratistas, especialmente de las compañías de seguridad que actúen en nombre del concesionario o quien haga sus veces, para lo cual deberá contar previamente con sentencia ejecutoriada dictada por Juez competente que determine violación de derechos humanos”.

29. En mérito de lo expuesto, me permito consignar el presente voto salvado esperando que los criterios aquí razonados sean considerados en futuros debates, a fin de profundizar sobre los efectos y alcance práctico del principio de prevención ambiental, que sin lugar a dudas no es un asunto que se encuentre del todo clarificado por la jurisprudencia constitucional.

Dra. Carmen Corral Ponce
JUEZA CONSTITUCIONAL

Razón.- Siento por tal que el voto salvado de la Jueza Constitucional Carmen Corral Ponce, en la causa 1149-19-JP, fue presentado en Secretaría General, el 24 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico a las 23:28; y, ha sido procesado conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL